

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2542

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

นาง เฟลีน สาร ภู ล

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสี่

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108, มาตรา 108 ทวิ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 มาตรา

ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิบัญญัติถึงผู้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 9 ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ หากผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่มาตรา 108 บัญญัติไว้ก่อนผู้ฝ่าฝืนจึงมีความผิดตามมาตรา 108 แต่ถ้ากระทำการฝ่าฝืนมาตรา 9 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 เป็นต้นไป ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 108 ทวิ มีความผิดทันที โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 จำเลย ปลุกบ้านในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามฟ้อง อันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันและ เป็นที่ดินของรัฐ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 9, 108, 108 ทวิ เมื่อได้ความว่าจำเลยปลุกบ้าน ตามฟ้องก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 จำเลยจึงไม่มีความผิด ตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 9, 108 ทวิ แม้อาจเป็น ความผิดตามมาตรา 9, 108 และโจทก์ได้อ้างมาตรา 108 มาด้วย แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงดังเช่นที่ปรากฏ ในทางพิเคราะห์มาในฟ้อง จึงไม่ใช่เรื่องที่โจทก์

ประสงค์ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่
จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรา 108 ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณ
หมู่ที่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ทางด้านทิศตะวันตกของ
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 21250 ของวัดเขาบางทราย ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันและเป็นที่ดินของรัฐ โดยจำเลยได้ปลูกสร้างบ้านรูก้ำ
เข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเนื้อที่ 12 ตารางวา โดยจำเลยไม่มีสิทธิครอบครองและไม่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
9, 108, 108 ทวิ และให้จำเลยคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยออกไป
จากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครอง ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินซึ่ง
เข้าไปยึดถือครอบครองด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยอัยการพิเศษประจำเขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการ
สูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 9(1), 108 ทวิ วรรคสอง จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกรอ
การลงโทษไว้ 1 ปีไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,

30 ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่เข้าไปยึดถือครอบครอง ให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยออกจากที่ดินที่เข้าไปยึดครอบครองด้วย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของภูมิจำนวน ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วห้ามมิให้บุคคลใด (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า ฯลฯ" มาตรา 108 บัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษ ฯลฯ" และมาตรา 108 ทวิ บัญญัติว่า "นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษ ฯลฯ" ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติตามที่มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิบัญญัติถึงนั้น คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 ดังนี้ จะเห็นได้ว่า มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิบัญญัติถึงผู้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 9 ออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ หากผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่มาตรา 108 บัญญัติไว้ก่อน ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จึงมีความผิดตามมาตรา 108 แต่ถ้ากระทำการฝ่าฝืนมาตรา 9 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 เป็นต้นไปแล้ว ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 108 ทวิ มี

ความผิดทันทีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ทั้งสิ้นดังนั้น
บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้จึงบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดมาตรา 9 ไว้ต่างกัน คดีนี้
โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลย
ปลูกบ้านในที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันและเป็นที่ดิน
ของรัฐ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108, 108 ทวิ แต่ได้
ความจากคำเบิกความนายสุรินทร์ ศรีวิเชียร นายช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี พยานโจทก์ตอบคำถามค้านว่าพยานไปรับราชการที่จังหวัดชลบุรี ปี 2510 ก็
เห็นบ้านจำเลยแล้วทั้งได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกจิรพงษ์ ศิริ
ประเสริฐโชคพนักงานสอบสวนตอบคำถามค้านว่า ทราบว่าบ้านของจำเลยปลูกอยู่
ก่อนปี 2512 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยปลูกบ้านตามฟ้องก่อนวันที่ 4 มีนาคม
2515 ซึ่งเป็นเวลาก่อนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2515 ใช้บังคับ ฉะนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะฟังว่า ที่ดินที่จำเลยปลูกบ้านบางส่วนเป็นทาง
สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันและเป็นที่
ดินของรัฐ โดยจำเลยไม่มีสิทธิครอบครองและไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า
หน้าที่จำเลยก็ไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิหากเป็น
ความผิดก็อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9, 108 และแม้โจทก์
จะอ้างมาตรา 108 มาด้วยแต่ตามข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวในฟ้อง โจทก์ไม่ได้
บรรยายถึงข้อเท็จจริงดังเช่นที่ปรากฏในทางพิจารณาจึงไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่ จึงไม่อาจ
ลงโทษจำเลยตามมาตรา 108 ได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลย
อีกต่อไป"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อภิศักดิ์ พรพชรภา-กนก พรพรณรักษา-วิชา มั่นสกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินของบุคคลทั่วไปเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 และมาตรา 4 นอกจากนั้นเป็นที่ดินของรัฐ คือ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด (มาตรา 2) แต่อาจมีผู้ได้รับอนุญาต (มาตรา 9 ทวิ) ให้เข้าไปกระทำการตามมาตรา 9(1)(2) และ (3) ได้ที่ดินของรัฐอาจมีการจัดหาผลประโยชน์ได้ (มาตรา 10) โดยอธิบดีกรมที่ดิน (บทนิยามมาตรา 1) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (บทนิยามมาตรา 1) มีอำนาจมอบให้ "ทบวงการเมือง" ใช้ประโยชน์ได้โดยมีบทห้ามผู้ฝ่าฝืนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและกำหนดโทษไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2542 นี้วินิจฉัยถึงความแตกต่างของประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) กับมาตรา 108 ทวิที่ยึดมิติ ด้านเวลาข้อจำแนกเพื่อการปรับบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ตามย่อฎีกานี้ในวรรคแรก และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166/2517 ซึ่งวินิจฉัยในปัญหาเดียวกันทั้งในประเด็นตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ในทำนองเดียวกัน ในระบบของกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดและกฎที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเด็นปัญหาหรือข้อวินิจฉัยในแต่ละประเด็นจึงมีเงื่อนไขของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นขอบบังคับแม้หลายกรณีจะมีลักษณะเป็นการเฉพาะกรณี แต่ก็มักได้

รับการอ้างอิงยึดถืออย่างค่อนข้างจะเคร่งครัด ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุและผลในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2542 ผู้หมายเหตุมีข้อพิจารณาดังนี้ 1. การใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญา 1.1 หลักทั่วไปต้องใช้กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นความผิดและกำหนดโทษสำหรับการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดนั้น ๆ ไว้ และกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ในขณะกระทำหมายความว่า "การกระทำทุกอันที่เป็นองค์ความผิดต้องได้กระทำในระหว่างที่กฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดขึ้นนั้นกำลังใช้บังคับอยู่" ดังนั้นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 (เดิม) ต้องพิจารณาว่ามีการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดเป็นความผิดสำเร็จแล้ว คือ มีการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 เมื่อใดศาลฎีกาเคยแปลบทบัญญัติมาตรานี้ไว้ว่า "ครบองค์ประกอบความผิดตั้งแต่ขณะเข้าไปยึดถือครอบครอง" ทั้งยังเป็นความผิดตลอดเวลาที่ครอบครองจึงต้องถือว่าการฝ่าฝืนมาตรา 9 ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 เป็นความผิดสำเร็จแล้ว 1.2 เงื่อนไขที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการทางปกครองต้องแจ้งให้ออกและมีคำสั่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 (ปัจจุบัน) ก่อนการดำเนินการทางคดีอาญาและต้องมีการฝ่าฝืนคำสั่งตามระเบียบนั้นเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญาฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 มีองค์ประกอบความผิดต่างจากประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ นั้น ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งหรือการออกคำสั่งตามระเบียบใดอีก เป็นความผิดทันทีที่ฝ่าฝืนมาตรา 9 นอกจากนั้นศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยกรณีระหว่างมาตรา 108 (ปัจจุบัน) กับมาตรา 108 ทวิ ไว้ว่าเป็นเรื่องบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดขาดสาระสำคัญจะลงโทษจำเลยตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ผลจากการยกเลิกประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 (เดิม) ซึ่งบัญญัติเพียงบท

ลงโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 เป็นมาตรา 108(ปัจจุบัน) ไม่มีบทบัญญัติโดยยกเลิกองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 แต่อย่างใดแต่เพิ่มขึ้นตอนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ และผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ต้องฝ่าฝืนคำสั่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) ด้วยจะมีผลทำให้การฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ที่เป็นการผิดสำเร็จแล้วนั้น กลายเป็นความผิดที่ยังไม่สำเร็จเพราะยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดใช่หรือไม่ หากใช้ภาวะที่ผู้กระทำฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ นั้นจะถือว่าอยู่ในชั้นพยายามกระทำความผิดหรือชั้นตอนใด 1.3 ผลจากการที่ถือว่าเงื่อนไขการแจ้งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) และการฝ่าฝืนคำสั่งตามระเบียบนั้นเป็นองค์ประกอบความผิด

1.3.1 มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ โดยบรรยายในฟ้องใหม่ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 (ปัจจุบัน) ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำเพราะความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108(ปัจจุบัน) นั้น "ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับจะมีความผิดต่อเมื่อได้รับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ออกจากที่ดินแล้วไม่ยอมออก"

1.3.2 ผลในทางอาญาของการฝ่าฝืนคำสั่งให้ออกจากที่ดินของรัฐ 1.3.2.1 กรณีที่ถือว่าต้องปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) นั้น หากไม่แจ้งหรือแจ้งคำสั่งให้ออกจากที่ดิน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ 7 นั้นถือว่าผู้ฝ่าฝืนยังไม่ทราบคำสั่ง "จึงยังไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368" ซึ่งแม้มิได้มีความหมายว่าหากส่งได้ถูกต้องจะทำให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 แต่ก็ชวนให้คิดไปเช่นนั้นได้ แต่อย่างก็ตาม เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108(ปัจจุบัน) บัญญัติไว้โดยเฉพาะ "ฉะนั้นจึงนำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 มาใช้บังคับลงโทษจำเลยไม่ได้" 1.3.2.2 ในทางปฏิบัติ

มักมีการแจ้งให้ออกจากที่ดินของรัฐก่อนเสมอ ก. แม้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 9 ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 และพนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนนั้นก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มักแจ้งหรือมีคำสั่งให้ออกจากที่ดินของรัฐก่อน เมื่อผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมออกจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 อีกกระทงหนึ่ง เพราะการฝ่าฝืน มาตรา 9 เป็นความผิดตั้งแต่ขณะเข้าไปยึดถือครอบครองแต่ความผิดฐานขัดคำสั่งเพิกเกิดเมื่อพ้น 30 วัน หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคำสั่ง จะถือว่าเป็นกรรมเดียวกันหาได้ไม่ ข. กรณีฝ่าฝืนมาตรา 9 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 ซึ่งต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ นั้นไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีคำสั่งหรือดำเนินตามขั้นตอนดังเช่นประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) เช่นกันแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ออกหากผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ไม่ยอมออกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 อีกกระทง กรณีตามข้อ 1.3.2.2 ก. และ ข. ถือว่าเป็นกรณีที่วินิจฉัยสอดคล้องต้องกัน แต่กรณีตามข้อ 1.3.2.1 นั้น น่าจะมีความแตกต่างโดยจะเห็นได้ว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 9 ซึ่งต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(เดิม) และตามมาตรา 108 ทวิ กับฐานขัดคำสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 เป็นต่างกรรมต่างวาระเป็นการกระทำที่แยกส่วนออกมาได้ทำนองเป็น "ต่างฐานกันและต่างเจตนาไปด้วย" นั้นเมื่อถือเป็นต่างกรรมจะยังคงเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ด้วยหรือไม่ ทั้งที่เป็นการกระทำเดียวกันและโดยเจตนาที่จะคงอยู่ในที่ดินของรัฐโดยการไม่ยอมออกจากที่ดินนั้น หากเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จะเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หรือไม่ ตามหลักทั่วไปกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจะต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งมีผลใช้บังคับขณะกระทำ และการกระทำที่ไม่ครบองค์ประกอบความผิดของฐานใดย่อมไม่อาจลงโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ

ตามแนววินิจฉัยที่ผ่านมาศาลฎีกาเห็นว่าต้องมีการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 9 ประกอบกับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งและมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 ออกจากที่ดินของรัฐแล้วผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งเป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จึงจะครบองค์ประกอบความผิดที่จะลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108(ปัจจุบัน) ได้ 2. การใช้กฎหมายที่เป็นคุณ การที่จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ตามบทกำหนดโทษในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(เดิม)ซึ่งถือว่าเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่ฝ่าฝืนและต้องดำเนินการตามขั้นตอนในทางคดีอาญาทันที ส่วนการที่ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108(ปัจจุบัน) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดนั้นมิใช่เป็นการยกเลิกองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 แต่เป็นมาตรการที่ทำให้ความเคร่งครัดของการที่จะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ตามบทกำหนดโทษในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(เดิม)ผ่อนคลายลงโดยมีระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติและมีผลทำให้ผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 มีโอกาสที่จะได้รับอนุญาตตาม"ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515)ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ" หากได้รับอนุญาตจะทำให้การฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนนั้นเป็นการกระทำที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 9 อีกต่อไป หรืออย่างน้อยในระยะเวลาที่ระบุว่ายินยอมจะออกไปหรือในระหว่างเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ต้องออก ผู้ฝ่าฝืนยังไม่ต้องถูกดำเนินคดีในทางอาญาฐานฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อเริ่มต้นคดีทางอาญายังไม่ได้ โดยตามระเบียบนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนอยู่ที่เวลาที่กำหนดในคำสั่งเป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งตลอดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดนี้ ผู้ฝ่าฝืนยังไม่ต้องถูก

ดำเนินคดีทางอาญาหากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมแก้ไขโดยไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ออกและตามคำสั่งเป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้ออกจากที่ดินของรัฐถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้นให้ ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108(ปัจจุบัน) จึงเป็นคุณแก่ผู้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 มากกว่ากรณีตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108(เดิม) ดังนั้นในการใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) กับการกระทำที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 นั้น ผู้หมายเหตุเห็นว่ากรณีเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณไม่ว่าทางใด ไม่ว่าส่วนที่เป็นคุณอยู่ในกฎหมายขณะกระทำหรือในกฎหมายใหม่ ใช้ได้ทุกอย่างในส่วนที่เป็นคุณ และ "เป็นบทบัญญัติที่ศาลจะต้องนำไปใช้บังคับ หาใช่เป็นเรื่องดุลพินิจที่ศาลจะนำไปใช้หรือไม่ก็ได้" การใช้กฎหมายที่เป็นคุณในกรณีนี้จะต้องใช้อย่างไร เช่น โทษที่จะลง อายุความจะใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(5) หรือ (4) ฯลฯซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยต่อไป 3. กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 3.1 กรณีตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108(เดิม) เมื่อมีการกระทำที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 และพบการกระทำที่ฝ่าฝืนนี้ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2515 พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้มีการร้องทุกข์หรือจับกุมเพื่อดำเนินคดีอาญาได้ทันที เพราะถือเป็นความผิดสำเร็จการพิสูจน์ความผิดไม่ว่าในแง่องค์ประกอบภายนอกหรือองค์ประกอบภายใน เป็นกระบวนการในชั้นพิจารณาของศาลและลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(เดิม) 3.2 กรณีตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108(ปัจจุบัน) เมื่อมีการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับ (ใช้บังคับวันที่ 4 มีนาคม 2515) แต่พบการกระทำความผิดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 นั้นจะลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) แทนที่ไม่ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนคดีอาญา เพื่อลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108(ปัจจุบัน) ได้ กฎหมายใช้คำว่า "มีอำนาจ" แจ้งเป็นหนังสือให้ "ผู้ฝ่าฝืน"ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด" คำว่า "มีอำนาจ" นั้น หมายถึง "มีหน้าที่และต้องกระทำ" ดังเช่นที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยยกฟ้องโดยเหตุที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515) ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9ฯ ข้อ 7 ถือว่ายังไม่มี การแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนทราบ จึงยังไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 และ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) 3.3 กฎหมายยังคงถือว่าเป็น "ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9" อยู่โดยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) และมาตรา 108 ทวิ ใช้คำว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9" ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9"ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(เดิม) รวมทั้งคำว่า"ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9" หรือคำว่า "ผู้ฝ่าฝืน" ตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515)ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 ฯ แต่ในหมวด 3 ซึ่งเป็นเรื่องการขอเข้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์เรียกว่า "ผู้ขอ" หรือ "ผู้ได้รับการผ่อนผัน"หากได้รับอนุญาตหรือได้รับการผ่อนผันหรือยินยอมออกจากที่ดินของรัฐตามระเบียบนี้ย่อมพ้นจากภาวะการเป็น "ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9"หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบ น้าระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ฝ่าฝืนมาใช้โดยอนุโลม ผู้หมายเหตุมีความเห็นว่าตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) ไม่ได้มีผลทำให้การเป็น "ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9" ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 กลายเป็น "ผู้ไม่ฝ่าฝืน" แต่อย่างใดแต่การจะให้ผู้

ฝ่าฝืนได้รับโทษจะต้องดำเนินการอย่างไร จะลงโทษใดเพียงไร หรือให้ผู้ฝ่าฝืนมีสิทธิ
แก้ไขอย่างไร หรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง สถานะของการเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 นั้น
ยังคงอยู่ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนและตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนของพนักงานเจ้า
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการ ทั้งการแจ้งให้ออกจนกระทั่งสิ้นสุดเวลาที่กำหนดในคำสั่งเป็น
หนังสือให้ออก ถือว่าเป็นระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ แต่เมื่อมีคำสั่งเป็น
หนังสือให้ออกแล้วไม่ยอมออกไปตามที่กำหนดถือว่าระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้น
โทษให้ นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และเป็นขั้นตอนที่ยืนยันว่าผู้กระทำความผิดจะฝ่าฝืน
มาตรา 9 อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการยืนยันความเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ต่อไป
โดยมี "กรรม" คือ "การฝ่าฝืนคำสั่งเป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด" เป็นเครื่องชี้เจตนาผู้ฝ่าฝืนไม่อาจยกข้อต่อสู้เรื่อง
การขาดเจตนาขึ้นต่อสู้ได้อีกต่อไป และไม่อาจอ้างได้ว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าได้
รับอนุญาตให้อยู่ในที่ดินของรัฐ การที่ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
108(ปัจจุบัน) ระบุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยการแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามระเบียบ กระทั่งการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินของรัฐ ผู้
หมายเหตุเห็นว่าเมื่อไม่ระบุบรรยายในฟ้องว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บัญญัติใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) จนครบถ้วนซึ่งอาจเกิดจากการรวบรวม
ข้อเท็จจริงไม่บริบูรณ์ นอกจากจะเป็นเรื่ององค์ประกอบความผิดหรือเป็นเรื่องที่
โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษดังเช่นที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วยังเป็นกรณีไม่ครบ
เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดอำนาจฟ้องคดีฐานฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และ
ไม่มีอำนาจที่จะลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108(ปัจจุบัน) ด้วยเพราะ
ไม่สามารถทราบได้ว่าสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้นโทษเมื่อใด ซึ่งเป็นกรณี
กฎหมายที่เป็นคุณและศาลต้องใช้หาใช้ดุลพินิจของศาลไม่ จึงพิพากษาลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108(ปัจจุบัน) ไม่ได้ สุรพลสุขอัจจะสกุล